

1531308-43.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Daniela Pazzeto Meneghine Conceição

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 11ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/06/2022

... para a condenação do réu pelos crimes de tráfico de entorpecentes e receptação.

Quanto ao delito de tráfico, restou incontroverso que o réu trazia consigo, para entrega e consumo alheio, substâncias entorpecentes denominadas popularmente como cocaína e crack.

Os depoimentos dos policiais demonstraram de modo firme e convincente o flagrante ocorrido, descrevendo toda a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

11ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, 1º andar, sala 189 - Barra Funda

CEP: 01133-020 - São Paulo - SP

Telefone: (011) 2127-9021 - E-mail: sp11cr@tjsp.jus.br

1531308-43.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1531308-43.2021.8.26.0228 - 2022/000028

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS SANTOS SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Daniela Pazzeto Meneghine Conceição.

Vistos,

LUCAS SANTOS SILVA foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 e no artigo 180, caput, do Código Penal, ambos c.c o artigo 61, inciso II, alínea "j", na forma do artigo 69, do Código Penal, porque, no dia 26 de dezembro de 2021, por volta das 10h10min, na Avenida Parada Pinto, 1380, Cachoeirinha, nesta cidade e Comarca, em situação de calamidade pública de saúde causada pela pandemia do coronavírus (COVID-19), trazia consigo, para fins de tráfico e entrega a consumo de terceiros, 60 (sessenta) porções de cocaína com peso líquido de 21,6 gramas e 26 (vinte e seis) porções de cocaína, na forma de "crack", com peso líquido de 4,4 gramas, substâncias consideradas drogas, que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Ainda, entre os dias 17 de setembro e 25 de dezembro de 2021, em local incerto, mas nesta cidade e comarca, em situação de calamidade pública de saúde causada pela pandemia do coronavírus (COVID-19), LUCAS SANTOS SILVA, recebeu o aparelho celular Samsung, IMEI 358692107861926, sabendo tratar-se produto de crime.

A denúncia foi recebida em 14/01/2022 (fls. 106/107).

O réu constituiu advogado e apresentou defesa prévia (fls. 114/134).

Mantido o recebimento da denúncia, foi deferida a gratuidade de justiça ao réu e foi designada audiência de instrução e julgamento (fls. 168/171).

Durante a instrução foram as testemunhas de acusação e defesa, e, ao final, o réu foi interrogado.

Em debates, o Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia.

A defesa, por sua vez, requereu a absolvição do réu, bem como a liberação do veículo.

É O RELATÓRIO
DECIDO

A pretensão acusatória é parcialmente procedente.

A materialidade delitiva está consubstanciada no autor de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência nº BE0284-1/2021 (fls. 07/10), boletim de ocorrência referente ao delito anterior ao da receptação (fls. 11/13), auto de exibição e apreensão (fls. 16/18), laudo de constatação preliminar (fls. 22/25), fotografias (fls. 26/29), laudo de exame químico-toxicológico (fls. 161/163), e pela prova oral constante nos autos.

A autoria também é certa.

Segundo consta na denúncia, no dia 17 de setembro de 2021, o aparelho celular Samsung, IMEI 358692107861926, pertencente à vítima Edilson, foi roubado por dois indivíduos não identificados. Após, em dia incerto, o réu recebeu o bem, sabendo de sua origem ilícita.

Posteriormente, em 26 de dezembro, o réu dirigiu-se à via pública conduzindo o veículo Fiat/ Palio, placas EPJ-2526, no contrafluxo da avenida Parada Pinto em alta velocidade, na posse do citado aparelho e de substâncias entorpecentes, quando policiais militares em patrulhamento o avistaram e decidiram pela abordagem.

Em revista pessoal, foi encontrado no bolso da bermuda do réu 20 (vinte) saquinhos plásticos de cocaína. Indagado, LUCAS afirmou que seriam vendidos, sem outros detalhes. Ele também confessou mais entorpecentes debaixo do banco do motorista, onde, de fato, foram localizadas 40 (quarenta) porções de cocaína e 26 (vinte e seis) trouxinhas de crack.

Ainda, no outro bolso de LUCAS foi localizado o aparelho celular fruto de crime de roubo. O réu afirmou informalmente aos policiais militares que o adquiriu sem conhecimento da origem ilícita, mas não apresentou justificativa alguma para comprovar seu álibi.

Perante a d. Autoridade Policial, o réu Lucas Santos Silva negou os fatos, dizendo desconhecer as drogas e o celular apreendido (fls. 05). Afirmou que estava na posse

do veículo Fiat/Palio desde quinta-feira e que nada de ilícito havia no veículo, o qual foi lavado neste período. Afirma que nada de ilícito portava e que não portava entorpecentes. Não havia entorpecentes no veículo e não reconhece o celular apreendido como sendo de sua propriedade. Não estava na posse do celular. Não sabe onde estavam os entorpecentes e o celular. Havia acabado de deixar sua namorada no trabalho e retornava à residência. Não é habilitado para conduzir veículos e pegou o veículo emprestado de seu primo Mateus. Não sabia do chassi cortado do veículo. Estava em saída temporária e deveria retornar segunda-feira.

Em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o réu voltou a negar os delitos a ele imputados. Afirmou que no dia dos fatos havia acabado de deixar sua namorada em seu trabalho e, ao retornar pela mesma avenida se deparou com uma viatura policial que logo em seguida, lhe deu sinal de parada. Atendida a ordem, foi revistado por uma policial feminina, o que achou estranho, sendo que nada de ilícito portava. Depois de cinco minutos, se aproximou outra viatura, momento em que uma dos policiais fez um sinal ao outro de que tudo estava tranquilo, razão pela qual foram embora. Em seguida, um dos policiais o indagou se possuía passagens criminais, tendo respondido afirmativamente, perguntando ainda o que possuía no bolso, quando então esclareceu que possuía um cheque no valor de R\$ 108,00, entregue pela colônia, bem como uma carteirinha. Neste instante, ele voltou para a viatura e quando retornou afirmou que queria que entregasse um "oitão", pois caso contrário ia acabar com sua vida. Neste instante chegaram mais umas quatro viaturas, quando então o policial falou que ia revistar seu veículo o que não se opôs. E seguida, quando estava no interior do veículo, o policial chegou a mostrar um celular, perguntando "se era sua ou dele", pelo que negava. Depois levantou uma blusa toda enrolada, vindo a perguntar "se era sua ou dele", quando de igual forma, negou a propriedade da mesma. Depois esta blusa foi passada para os demais policiais, sendo em seguida colocado no camburão. Declarou que à todo momento os policiais afirmavam que ia acabar com sua vida caso não entregasse um "oitão". Como estava sendo pressionado e, acreditando que ia ser morto pelos milicianos, falou que poderiam ir até o trabalho de sua mulher que ela resolveria. Enquanto ficou em poder de uma viatura, os policiais que estavam em outra para lá se dirigiram e, depois de uns quinze a vinte minutos retornaram afirmando que era mentiroso, pois sua mulher não tinha nada para entregar. Também pediu que conversassem com seu pai. Continuaram exigindo que entregasse um "oitão", caso contrário ia acabar com sua vida. Durante o percurso para a delegacia, pararam em uma lombada eletrônica, quando então chegaram mais duas viaturas, foi quando veio o comandante em sua direção e o indagou se havia resolvido. Pediu que falasse com seu pai e, depois de aguardar dez minutos, falou que ia enterra-lo vivo, vindo a encaminha-lo para o 13º DP. Disse que somente teve ciência do quê estava acusando na delegacia. Nega a propriedade das drogas e celular apreendido. Não conhecia os policiais anteriormente e acredita que eles nada tinham contra sua pessoa. Um dos policiais, que era careca, disse que o conhecia de outra ocorrência, mas não se recorda dele. Por fim, esclarece que estava em saída temporária.

A fala do réu, contudo, encontra-se isolada com o restante do conjunto probatório, não havendo dúvida de que o acusado praticou os delitos que lhe são imputados.

A testemunha Paula Regina Racham Basaglia, policial militar e presente na diligência que prendeu o réu em flagrante, relatou que estava em patrulhamento quando um veículo passou em alta velocidade, o que gerou suspeita. Feita a abordagem, com o réu havia um pouco de drogas em um de seus bolsos e no outro bolso havia um celular. Na ocasião, o réu afirmou que o veículo era de um primo. Foi verificado que o veículo estava com o chassi rasgado. No interior do veículo, havia mais drogas embaixo do banco do motorista. Não conhecia o réu anteriormente. O réu afirmou que as drogas eram para venda para passar o fim do ano. O réu estava em saída temporária. Quanto ao celular, foi constatado que era produto de furto/roubo. O réu afirmou que o celular era de sua mulher.

No mesmo sentido é o depoimento da testemunha Douglas Chagas dos Santos, também policial militar e presente na diligência. Disse que estavam em patrulhamento pela via, quando avistaram um veículo no contrafluxo em alta velocidade. Fizeram o retorno e realizaram a abordagem, tendo sido encontrado com o réu um aparelho celular e uma certa quantia de drogas em seu bolso. Indagado sobre os entorpecentes, o réu contou que havia mais no veículo. Quanto ao celular, foi verificado que era produto de roubo. No veículo havia mais drogas debaixo do banco do motorista. Não conhecia o réu anteriormente e ele não apresentou resistência. Foi verificado também que o chassi do veículo estava cortado. Não se recorda quanto tempo decorreu entre a abordagem e o encaminhamento do réu para a delegacia. O réu afirmou que o veículo era do primo dele. No local chegaram outras viaturas para apoio, o que é de praxe. Toda abordagem foi dentro da normalidade. Quando avistaram o veículo trafegando, ele estava em velocidade incompatível com a via. As viaturas foram até à empresa da esposa e à casa do genitor do réu porque ele afirmou que seu filho estava sozinho na residência, e, então, foram comunicá-los do ocorrido. Não é procedimento da polícia fazer isso, mas somente agiram assim por se tratar de uma criança que se encontrava sozinha em casa. O procedimento é fazer toda a averiguação e depois encaminhar até a delegacia. Desconhece que o réu tenha passado por outras delegacias.

Como é cediço, os agentes públicos de segurança não estão, com efeito, legalmente impedidos de depor e o valor de seus depoimentos não pode ser sumariamente desprezado, sobretudo quando se harmoniza com outros elementos de prova idôneos.

Seus depoimentos devem ser levados em consideração até prova em contrário, pois o Estado os credencia para exercer serviço público relevante, mediante rigorosos critérios de seleção.

Assim, salvo prova indubitosa de suspeição ou parcialidade do agente, inexistente nos autos, não se pode recusar eficácia probante a seus testemunhos que, como outro qualquer, constitui importante elemento de convicção, servindo seus relatos, à mingua de circunstâncias aptas a lhes comprometer a credibilidade, para a formação do convencimento judicial.

Por sua vez, a testemunha de defesa Flávio de Santana Silva afirmou que é genitor do réu e não estava presente na abordagem, mas compareceu ao distrito. Soube que seu filho estava detido por porte de drogas, pois uma viatura esteve em sua casa por volta de 12h30/13h. Na delegacia, o réu informou que já estava detido desde as 9h. Na delegacia, conversou com um policial para saber o que tinha acontecido e ele afirmou que não tinha sido encontrado nada com Lucas. Ao conversar com Lucas, ele disse que os policiais lhe falaram que se arrumasse uma arma o liberavam. Ainda, Lucas afirmou que a policial feminina falou para ele "você viu que eu não fiz nada". Lucas estava de "saidinha" e deve pagar pelo que fez, porém, contratou a advogada, pois acredita que neste caso seu filho está sendo injustiçado. Viu que os policiais estavam sendo contraditórios e estavam mentindo.

Já a testemunha de defesa Lucilene Ribeiro Barbosa, disse que é companheira do réu e não estava presente na abordagem, mas esteve com ele momentos antes, pois ele havia a deixado no trabalho. Estava no local de trabalho quando chegou uma viatura e comunicou que Lucas havia sido abordado e que ela teria que ir embora para cuidar do filho, que estava em casa, pois era para o Lucas voltar para casa e cuidar da criança. Na delegacia soube que os policiais estavam querendo uma arma para liberar ele. O réu a deixou no serviço e bateu o ponto às 9h07m. Os policiais chegaram em seu trabalho era mais de meio dia. Chegou ao mesmo instante em que Lucas chegou a delegacia e isso já era mais de 14h. Não sabe o nome dos PM's, pois não estavam identificados. O Lucas já foi processado por assalto (art. 157, CP) e porte de arma. Os policiais queriam uma arma de Lucas, pois ele estava de saidinha, ou seja, cumprindo pena, mas faltava pouco para ganhar a liberdade. Lucas não conhecia os policiais, mas um dos policiais disse que já tinha prendido ele anteriormente.

Quando chegou a delegacia, o réu estava no interior do distrito. Lucas estava preso, saiu na quinta e o fato ocorreu no domingo. Lucas não tem celular e não estava com nenhum celular. Também não havia drogas. O réu estava no local porque a tinha deixado no trabalho. Trabalha há 15 anos no comércio e a loja fica Avenida Parada Pinto.

Por fim, as testemunhas do juízo Luís Carlos Pelissari, Clayton Henderson Costa, juízo Marcus Vinicius Mota dos Santos e Pedro Henrique Lima Barbosa relataram que apenas participaram como equipe de apoio à ocorrência, sendo os responsáveis pelo encaminhamento das drogas apreendidas, as quais estavam devidamente lacradas, para serem levadas ao Instituto de Criminalística. No mais, não souberam precisar o tempo que durou a abordagem. Também não mantiveram contato com o réu.

Destarte, o conjunto probatório carreado aos autos, mostra-se suficiente para a condenação do réu pelos crimes de tráfico de entorpecentes e receptação.

Quanto ao delito de tráfico, restou incontroverso que o réu trazia consigo, para entrega e consumo alheio, substâncias entorpecentes denominadas popularmente como cocaína e crack.

Os depoimentos dos policiais demonstraram de modo firme e convincente o flagrante ocorrido, descrevendo toda a operação até a apreensão das drogas em poder do réu. Segundo seus relatos, estavam em patrulhamento, quando avistaram o réu trafegando no contrafluxo em alta velocidade. Feita a abordagem, no bolso da bermuda, foi encontrada parte da droga e, no interior do veículo, debaixo do banco do motorista, estava o restante das substâncias entorpecentes apreendidas. Ainda, em posse do réu, foi encontrado um aparelho celular produto de roubo. Além disso, ele estava em saída temporária em razão de cumprimento de pena no regime semiaberto.

Com efeito, as circunstâncias que antecederam e concorreram à prisão em flagrante do acusado, a natureza, variedade e quantidade das substâncias apreendidas (60 porções de cocaína com peso líquido de 21,6 gramas e 26 porções de cocaína, na forma de "crack", com peso líquido de 4,4 gramas), bem como a forma como estavam acondicionadas, em porções individuais, prontas para a comercialização, além de parte das drogas estarem escondidas debaixo do banco do veículo, conforme fotografias de fls. 26/27, estando ainda em posse de um aparelho celular produto de roubo e em saída temporária, indicam que o réu as trazia consigo com o único fim de entregá-las ao consumo de terceiros.

Inegável, portanto, a destinação dos entorpecentes ao comércio ilícito, diante da quantidade, variedade e forma de acondicionamento dos entorpecentes, circunstâncias e local da apreensão.

Ademais, não é crível afirmar-se que os policiais apreenderam substancial quantidade de entorpecente, e ainda, um celular produto de roubo, para incriminar inocente, que sequer o conheciam até a data dos fatos, como admitido pelo próprio réu, em seu interrogatório.

Ao contrário do alegado pela defesa, não se admitem insurgências generalizadas contra depoimentos de servidores policiais. Presume-se a imparcialidade na execução de seus trabalhos, até porque não há qualquer indício de desavenças por parte dos agentes em relação ao réu, que os motivassem a construir todo um plano tão somente para incriminar pessoa inocente.

Ressalta-se, ademais, que a abordagem policial decorre do exercício do Estado do poder de polícia, que tem o dever de prevenir delitos e condutas que representem ofensa à ordem pública. No caso, os policiais militares avistaram o réu em atitude suspeita, trafegando em alta velocidade, e, realizada a abordagem, encontraram as drogas no bolso de sua bermuda e escondidas no interior do veículo.

O fato é que trazer consigo é fato típico penal e o acusado foi surpreendido na posse das drogas. A ação policial, portanto, resultou na apreensão das drogas e na prisão em flagrante do acusado. Assim sendo, diante desse cenário não há que se falar em ausência de justificativa para a abordagem do acusado.

Nem mesmo a versão apresentada pelo réu de que os policiais estariam exigindo a entrega de uma arma e que, portanto, o flagrante seria forjado, condiz com o depoimento prestado por sua companheira. Isto porque, segundo o réu e, com medo de que algo lhe acontecesse, teria dito aos policiais para ir até o emprego de sua companheira que ela poderia "resolver" isso, ou seja, providenciar a entrega de uma arma. Ocorre que, ao ser ouvida em Juízo, a companheira do réu, Lucilene, apenas veio confirmar exatamente o que fora dito pelos policiais, ou seja, de que eles teriam comunicado a prisão de Lucas e a necessidade de que ela retornasse para sua casa, pois seu filho estaria sozinho. Disse ainda que somente na delegacia soube que os policiais estariam exigindo do réu a entrega de uma arma para assim liberá-lo.

No mesmo sentido constou do relato do genitor do réu.

A versão exculpatória do réu, portanto, mostra-se falsa quando confrontada aos depoimentos das testemunhas de acusação e defesa.

Já as imagens da câmera de segurança do estabelecimento próximo ao local da abordagem, não foram esclarecedoras a corroborar a versão apresentada pela defesa técnica. Isto porque, de péssima qualidade, não sendo possível extrair das filmagens, a alegada inocência, ou seja, de que os policiais nada teriam encontrado em poder do acusado. Pelo contrário, apenas corroboram toda ação delituosa, tal como narrada pelos policiais militares.

Com efeito, o ônus de provar situação diversa da citada é do réu, como ensina Damásio de Jesus:

Em processo penal, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer. É a regra contida na primeira parte da disposição. Assim, a prova deve ser feita por quem alega o fato, a causa ou a circunstância. Se o Ministério Público oferece denúncia contra o réu por crime de homicídio, incumbe ao órgão da acusação demonstrar a prática do fato e sua autoria. No tocante ao fato concreto cometido pelo sujeito, incumbe à acusação a prova dos elementos do tipo, sejam objetivos, normativos ou subjetivos. Em relação aos delitos materiais, a prova acusatória deve estender-se à demonstração da realização da conduta, da produção do resultado e do nexo de causalidade entre uma e outro. A prova do dolo e da culpa, elementos do tipo, incumbe também à acusação (contra, no sentido de que em decorrência da demonstração do dolo e da autoria o dolo é presumido: TJRJ, ACrim 1.316, RT 649/302). Agora, se o réu, na resposta escrita (art. 396 e 396- A), alega ter agido em legítima defesa, a ele compete a prova da excludente da ilicitude. O acusador deve provar a realização do fato; o acusado, eventual causa excludente da tipicidade, da antijuridicidade, da culpabilidade ou extintiva da punibilidade.

No entanto, em que pese o esforço da combativa Defesa, tem-se que nenhuma prova quanto ao alegado pelo réu foi produzida nos autos, não lhe socorrendo as testemunhas de defesa e demais provas juntadas aos autos.

Patente, portanto, a traficância.

Ainda, de acordo com a prova coligida em Juízo, restou incontroverso que o réu recebeu, em proveito próprio, aparelho celular Samsung, pertencente à vítima Edilson Barroso Lima, sabendo tratar-se produto de crime.

Como se vê, os policiais militares relataram de forma harmônica e coerente que, realizada a revista pessoal, encontraram o aparelho celular no bolso da bermuda do réu.

Quanto ao dolo do crime de receptação, cumpre anotar que nem sempre se terá prova direta, objetiva e concreta a respeito dos fatos, cabendo ao julgador, exatamente como se faz na espécie, a busca de elementos e evidências indiretas e relacionadas, aí sim, diretamente ao delito imputado.

A respeito da apuração do elemento subjetivo no crime de receptação já se manifestou a jurisprudência pátria:

Apelação criminal. Receptação simples. Dolo. Tipicidade subjetiva. Aquela pessoa que é surpreendida na condução direta de um veículo automotor precisa ter uma explicação verossímil e minimamente consistente sobre a origem do bem que tem em suas mãos, inclusive ensejando a sua Defesa técnica a produção de meios de prova convincentes que a referendem. Na cultura comum do povo, a condução de veículos automotores em via pública é ato que demonstra assenhoração e riqueza. Mas todos também sabem que é conduta que não prescinde de porte de documento de propriedade do veículo e a regularidade da detenção da coisa pela pessoa que assim procede. Diante disso, explicações puramente evasivas marcam indicações seguras do dolo direto que anima a pessoa a respeito da origem criminosa do carro, origem esta que ela procura, com suas respostas avulsas e incertas, inequivocamente esconder. Nunca é demais frisar que o dolo, posto que elemento típico puramente anímico e interno, em todo qualquer delito somente pode ser afirmado, ou infirmado, pelas circunstâncias com que a conduta concretamente se revela ao mundo exterior. Tal, por excelência, é o caso da pessoa que receptou dolosamente o veículo e que, ao conduzi-lo ostensivamente por via pública como se sua senhora fosse, ao ser surpreendida por policiais busca então subtrair-se à ação da justiça criminal com versões lacônicas, frágeis, pueris e jamais comprovadas sobre os descaminhos com que o veículo chegou até suas mãos.

E examinando as circunstâncias da hipótese vertente, claro se afeiçoa o dolo do agente, restando insubsistente qualquer versão exculpatória, no sentido de que desconhecia a origem espúria do bem receptado.

Logicamente tal ilação só pode ser feita em situação clara e cristalina, exatamente como no caso em análise, no qual os indícios de que o réu atuou dolosamente na receptação são muitos, concatenados e aptos a gerar a pretendida condenação.

Isso porque no dia 26/12/2021 o réu foi surpreendido na posse de um aparelho celular produto de crime, cujo proprietário é Edilson Barroso Lima, vítima de roubo ocorrido no dia 17/09/2021, conforme boletim de ocorrência de fls. 11/13. Assim sendo, cabia ao réu justificar os fatos, de forma a afastar a sua responsabilidade penal, o que não se verificou no caso em comento.

Com efeito, quando o agente é detido na posse de objeto produto de crime, cabe a ele provar sua boa-fé em relação à posse do objeto, sem que isto implique inversão do ônus da prova (CPP, art. 156), consoante entendimento sedimentado pelo c. STJ.

Porém, nada apresentou o réu em solo policial ou em juízo a justificar a posse do aparelho celular. Além do mais, o acusado estava também na posse de entorpecentes e em saída temporária.

Assim, não há como se alegar desconhecimento da origem espúria ou, ainda, hipótese de crime culposos. O dolo na conduta do acusado é evidente nesse caso.

Não restam dúvidas, portanto, de que o réu praticou a infração penal de receptação, eis que recebeu, para proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, o que

restou suficientemente demonstrado no curso da instrução processual.

No mais, deve ser reconhecido o concurso material entre os delitos atribuídos ao réu, eis que, mediante mais de uma ação, praticou mais um de um crime, cada qual com objetividade jurídica distinta.

Por outro lado, não há que se falar na incidência da agravante pelo delito ter sido cometido em ocasião de calamidade pública (CP, art. 61, II, j), pois não há evidências de que tal situação esteja atrelada à conduta praticada pelo réu.

Neste sentido, já decidiu o C. STJ: A incidência da agravante do art. 61, II, j, do Código Penal exige demonstração de que o agente se valeu do contexto de pandemia para a prática do delito, o que não ocorreu na hipótese vertente.

Na mesma toada, é o entendimento do E. TJSP:

(...) Não incidência da agravante inserta no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal - Ausência de demonstração do nexo de causalidade entre a pandemia ocasionada pela COVID-19 e a conduta do recorrente. (...) (TJSP; Apelação Criminal 1516331-80.2020.8.26.0228; Relator (a): Ricardo Sale Júnior; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 13ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 13/07/2021; Data de Registro: 13/07/2021)

(...) Segunda fase. Agravante da calamidade pública. Art. 61, II, j. Necessidade de afastamento. Circunstância que se caracteriza quando o agente se aproveita da situação de calamidade. Compensação integral da confissão com a reincidência. Acréscimo de 1/3 pelo repouso noturno. Pena definitiva em 2 anos de reclusão. Regime fechado mantido. Apelo parcialmente provido. (TJSP; Apelação Criminal 1500619-74.2021.8.26.0047; Relator (a): Guilherme de Souza Nucci; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Assis - 3ª Vara Criminal e da Infância e Juventude de Assis; Data do Julgamento: 09/07/2021; Data de Registro: 09/07/2021)

Destarte, assentes estão a materialidade e autoria delitiva, e a conduta do réu subsume-se, in totum, ao crime tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e art. 180, caput, do Código Penal, na forma no art. 69, também do Código Penal.

Passo a dosar a pena do réu.

Com relação ao delito tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06

Na primeira fase da dosimetria penal, atento aos critérios do art. 59, do CP, e art. 42, da Lei 11.343/06, observo ter sido o crime praticado durante a saída temporária de Natal. Trata-se de circunstância que é merecedora de maior censurabilidade. Também, verifico que o réu é reincidente, no entanto, tal apontamento será valorado na segunda fase da dosimetria (fls. 95/99).

Assim, pelas razões acima expostas, parto da pena-base elevada em um sexto, resultando em cinco anos e dez meses de reclusão e a solver quinhentos e oitenta e três dias-multa.

Na segunda fase reconheço a agravante da reincidência (art. 61, I, CP) havida dos seguintes processos: 1) F. 0010643-42.2019.8.26.0037, da r. 1ª Vara Criminal de Araraquara/SP, com trânsito em julgado para a defesa em 26/08/2020, pelo delito de porte ilegal de arma de fogo; 2) F. 0055717-85.2016.8.26.0050, da r. 25ª Vara Criminal Central/SP, com trânsito em julgado para a defesa em 18/06/2020, pelo delito de roubo; 3) F. 0097419-11.2016.8.26.0050, da r. 24ª Vara Criminal Central/SP, com trânsito em julgado para a defesa em 18/06/2018, pelo delito de roubo (fls. 95/99). Assim sendo, exaspero a pena em um quarto, resultando em sete anos e três meses e quinze dias de reclusão e ao pagamento de setecentos e vinte e oito dias-multa.

Não havendo causas de aumento ou diminuição de pena, mantenho a pena fixada.

Não é o caso de aplicação da causa de diminuição estabelecida no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, tendo em vista ser o réu reincidente, o que demonstra sua dedicação à atividade criminosa.

Convém mencionar que o fato de se considerar os maus antecedentes e a reincidência, nesta etapa da dosimetria da pena, para se afastar a aplicação do redutor do art. 33, § 4º da Lei 11.343/06, não implica em "bis in idem". Elas possuem finalidades distintas em cada fase de fixação da pena, gerando efeitos diversos.

Ser primário e com bons antecedentes é condição 'sine qua non' para que o traficante eventual possa merecer a causa especial de diminuição de pena. E o acréscimo pelo fato de o agente ter sido condenado anteriormente por sentença transitada em julgado, consubstancia agravante a ser aplicável em todo e qualquer processo criminal.

A matéria não é nova e já foi enfrentada com vagar pelo c. STJ:

Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto. - Por decorrer de expressa previsão legal descrita no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, inexistente bis in idem na utilização da reincidência como agravante e para justificar o afastamento do tráfico privilegiado, pois é possível que um mesmo instituto jurídico seja apreciado em fases distintas da dosimetria da pena, gerando efeitos diversos. Precedentes. - Hipótese em que o tráfico privilegiado não foi reconhecido com base na reincidência do acusado, fundamentação idônea e que não enseja constrangimento ilegal. [...] - Habeas corpus não conhecido.

Ainda:

Apenas ressalto que, consoante reiterada jurisprudência, a valoração dos maus antecedentes na primeira etapa da dosimetria, como circunstância judicial desfavorável, não é incompatível com a sua utilização, na terceira fase, para afastar a incidência da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, porquanto o referido instituto jurídico é sopesado com finalidades distintas em cada fase de fixação da pena, justamente para se alcançar a justa e correta reprimenda necessária para a reprovação e prevenção do delito perpetrado.

Não há, portanto, bis in idem.

Por tudo isto, diante da incompatibilidade dos requisitos para a aplicação do redutor com as circunstâncias acima expostas, impossível a sua incidência, já que a benesse, realmente, não deve ser aplicada de modo desmedido, prestigiando quem efetivamente mereça a redução da pena.

Assim, levando em consideração tais elementos, nego o benefício de redução da pena. Torno, portanto, definitiva a pena fixada alhures.

Quanto ao delito previsto no art. 180, caput, do Código Penal

Na primeira fase da dosimetria penal, atento aos critérios do art. 59, do CP, observo ter sido o crime praticado durante a saída temporária de Natal. Trata-se de circunstância que é merecedora de maior censurabilidade. Também, verifico que o réu

é reincidente, no entanto, tal apontamento será valorado na segunda fase da dosimetria (fls. 95/99).

Assim, pelas razões expostas, parto da pena-base elevada em um sexto, resultando em um ano e dois meses de reclusão e a solver onze dias-multa.

Na segunda fase reconheço a agravante da reincidência (art. 61, I, CP) havida dos seguintes processos: 1) F. 0010643-42.2019.8.26.0037, da r. 1ª Vara Criminal de Araraquara/SP, com trânsito em julgado para a defesa em 26/08/2020, pelo delito de porte ilegal de arma de fogo; 2) F. 0055717-85.2016.8.26.0050, da r. 25ª Vara Criminal Central/SP, com trânsito em julgado para a defesa em 18/06/2020, pelo delito de roubo; 3) F. 0097419-11.2016.8.26.0050, da r. 24ª Vara Criminal Central/SP, com trânsito em julgado para a defesa em 18/06/2018, pelo delito de roubo (fls. 95/99). Assim sendo, exaspero a pena em mais um quarto, resultando em um ano e cinco meses e quinze dias de reclusão e ao pagamento de treze dias-multa.

Não havendo causas de aumento ou diminuição de pena, torno definitiva a pena fixada.

Os crimes aconteceram em concurso material (art. 69, CP), pois cada qual tem objetividade jurídica distinta, devendo as penas serem somadas, chegando ao resultado final de oito anos e nove meses de reclusão e a solver setecentos e quarenta e um dias-multa, a qual torno definitiva diante da inexistência de outras modificadoras aplicáveis.

O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade deve ser o fechado, ante ao quantum de pena aplicada, as circunstâncias judiciais desfavoráveis, a reincidência e, ainda, a teor do art. 2º da lei federal 8.072/90, pois o crime de tráfico é equiparado a hediondo. A imposição de regime mais brando mostra-se incompatível com a gravidade do crime praticado.

O montante da pena, as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência não permitem quaisquer substituições ou favores legais.

Inexistindo informações acerca da situação financeira do réu, fixo o valor do dia-multa, para o delito, no padrão unitário, segundo o salário-mínimo vigente na data dos fatos, computando-se correção monetária, a partir de então, pelos índices de atualização da tabela prática editada pelo e. TJSP.

Posto isto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para condenar LUCAS SANTOS SILVA, RG: 49159440-9, CPF: 410.270.778-62, filho de Flávio de Santa Filho e Simone Flores dos Santos, às penas de 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime fechado, e a solver 741 (setecentos e quarenta e um) dias-multa, no padrão unitário, por violação ao art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, e art. 180, "caput", do Código Penal, na forma do art. 69, também do Código Penal.

Tendo em vista a ausência de modificação dos fatos que autorizam o decreto de prisão preventiva do réu, deve ser mantida a custódia cautelar, em face da presença do periculum libertatis, consubstanciada na garantia da ordem pública (CPP, art. 312), evidenciada na gravidade concreta da conduta e no alto grau de probabilidade de reiteração criminosa.

Nesse sentido, vem decidindo o c. STJ que a despeito do princípio da presunção de inocência, não tem direito de recorrer em liberdade o réu que permaneceu justificadamente preso durante toda a instrução criminal.

Inviável a aplicação do art. 387, §2º, do CPP, por falta de informações hábeis a respaldar não só a real situação processual do acusado, mas também os requisitos subjetivos indispensáveis à estipulação de regime diverso do ora imposto, cabendo

ao acusado pleitear o benefício que entende devido junto à Vara de Execução Criminal Competente.

Recomendo o réu na prisão em que se encontra recolhido.

Autorizo a expedição de guia de recolhimento provisória.

Fica autorizada a incineração das drogas apreendidas se acaso tal providência ainda não tiver sido realizada, nos termos do art. 32 e parágrafos da Lei 11.343/06.

Quanto ao veículo apreendido, com fundamento nos arts. 60, §6º (dado pela nova redação da Lei nº 14.322/22) e 63, ambos da Lei 11.343/06, decreto sua perda em favor da União e determino a venda em leilão.

Condeno o réu ao pagamento das custas equivalentes a 100 UFESP's, nos termos do art. 4º, § 9º, alínea "a" da Lei nº 11.608/03, verbas cuja execução suspendo (CPC, art. 98, §§ 3º e 4º).

Após o trânsito em julgado, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt - IIRGD; oficie-se ao e. TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da CF; expeça-se guia de execução definitiva, remetendo-a ao Juízo competente.

P.R.I.

São Paulo 02 de junho de 2022

Daniela Pazzeto Meneghine Conceição
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA